

緊急避難（刑法第37条第1項）に関する次の【記述】の中の①から⑥までの（ ）内に、後記アからスまでの【語句群】から適切な語句を入れた場合、（ ）内に入るものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの（ ）内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【記述】

緊急避難を（①）と解する見解によれば、その不処罰の根拠は、切迫した心理状態のために適法な行為を期待し得ないことに求められる。この見解によれば、緊急避難によって侵害を転嫁される第三者は緊急避難行為に対して（②）で対抗できることになる。この見解に対しては、刑法第37条第1項が（③）を守るための緊急避難を認めていることと整合しないという批判がある。他方、緊急避難を（④）と解する見解によれば、その不処罰の根拠は、法益が衝突する状況下で被侵害法益と同等以上の法益を保全する行為は社会全体の利益を（⑤）させるものではないことに求められる。また、この見解に立つと、緊急避難行為に対して（②）で対抗することを認めるのは困難である。さらに、緊急避難を基本的には（④）と解しつつ、保全法益と被侵害法益がいずれも生命である場合には、（①）であると解する見解もある。この見解は、自己又は第三者の生命に対する危難を避けるために無関係の第三者の生命を犠牲にする行為を（⑥）と評価するのは不当であるという考え方に基づくものである。

【語句群】

ア. 違法性阻却事由 イ. 責任阻却事由 ウ. 個人的法益 エ. 社会的法益
オ. 他人の法益 カ. 自己の法益 キ. 増加 ク. 減少 ケ. 正当行為
コ. 正当防衛 サ. 緊急避難 シ. 違法 ス. 違法でない

1. ①ア ③ウ ⑤ク
2. ①イ ③エ ⑤キ
3. ②ケ ④ア ⑥ス
4. ②コ ⑤ク ⑥ス
5. ③オ ④ア ⑥シ

No94	緊急避難	正答率 70%
共通R2-17	正 解	4

() には順に、「①イ ②コ ③オ ④ア ⑤ク ⑥ス」が入り、正解は肢4となる。

緊急避難の法的性質について、違法性阻却事由説、責任阻却事由説、原則的に違法性阻却事由であるが法益同価値の場合には責任阻却事由であるとする二分説がある。

まず、違法性阻却事由説は、37条1項が、避難によって生じた害が避けようとした害を超えないことという法益の均衡を要求していることを根拠に、避難行為の違法性が阻却されるとする見解である。この見解からは、避難行為に対する反撃は、「正対正」の場面として、正当防衛（36条1項）は、成立し得ないことになる。この見解に対しては、保全法益と侵害法益が同価値の場合の違法性阻却の根拠が明らかでないとの批判がある。

次に、責任阻却事由説は、避難行為には、違法性があるが、危難に直面している状態では他の適法な行為についての期待可能性がないことを根拠に、責任が阻却されるとする見解である。この見解からは、避難行為に対する反撃行為は、「不正対正」の場面として、正当防衛が成立しえる。この見解に対しては、37条1項は他人の法益に対する緊急避難を認めている以上、他に適法行為を期待できないという理由だけで犯罪が不成立になるとは考えられないとの批判がある。

そして、二分説は、保全法益が侵害法益に優越するかがりて、優越的利益の原則を根拠に違法性が阻却され、法益同価値の場合には、この原則は適用されず、期待可能性がないことを根拠に責任が阻却される見解である。この見解に対しては、責任阻却事由説と同様の批判がある。

①について

①には、緊急避難の法的性質について、期待可能性がないことを根拠とする見解に関する語句が入る。したがって、①には「イ. 責任阻却事由」が入る。

②について

②には、避難行為に対する反撃について、責任阻却事由説からの帰結に関する語句が入る。したがって、②には「コ. 正当防衛」が入る。

③について

③には、責任阻却事由説に対する批判に関する語句が入る。したがって、③には「オ. 他人の法益」が入る。

④について

④には、避難行為に対する反撃について、②「コ. 正当防衛」で対抗することを認めないとする見解であり、かつ、二分説以外の見解に関する語句が入る。したがって、④には「ア. 違法性阻却事由」が入る。

⑤について

⑤には、違法性阻却事由説の根拠に関する語句が入る。したがって、⑤には「ク. 減少」が入る。

⑥について

⑥には、保全法益と侵害法益が同価値である場合の、二分説の考え方に関する語句が入る。したがって、⑥には「ス. 違法でない」が入る。